

1501028-65.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... que a droga realmente se destinava ao tráfico.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a finalidade de tráfico de entorpecentes é evidente.

Ressalto, apenas, que não há prova alguma nos autos de que o réu estaria sendo ameaçado/coagido por alguém a praticar o tráfico, muito menos de que essa suposta coação seria irresistível, de forma que inaplicável ao caso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1501028-65.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501028-65.2020.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

V I S T O S.

PEDRO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 16 de julho de 2020, por volta das 21:36 horas, na residência situada na Rua Dionísio da Costa, nº 24, no Bairro Country Ville, nesta cidade e Comarca de Araçatuba, trazia consigo, para fins de tráfico, 10,90 gramas de cocaína, divididos em quinze microtubos plásticos, substância esta que causa dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado (fls. 98) e apresentou defesa preliminar a fls. 105/110. A denúncia foi recebida a fls. 115/117. No decorrer da instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (fls. 138/139) e, após, interrogado o acusado

(fls. 140/141).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 164/170), ao passo que o Dr. Defensor, por sua vez, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no 33, §4º da Lei 11.343/06, o afastamento da agravante decorrente da pandemia e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 189/208).

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, laudo de constatação provisória de fls. 22 e exame químico de entorpecentes encartado a fls. 70/72, que resultaram positivos para cocaína.

E a responsabilidade criminal do acusado é indubitosa.

Com efeito, ao ser interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do crime. Disse que possuía uma dívida referente a drogas com um traficante de nome Talisson, que começou a ameaçá-lo. Pegou 15 pinos de cocaína para vender e abater na dívida. Esclareceu que cada pino era comercializado por 10 reais. Por fim, disse que já teve passagem na Vara da Infância por tráfico de drogas e que não conhecia os policiais.

E a confissão do acusado foi corroborada pelos policiais Renan Gustavo Coraza e Eder Luiz de Mattos, os quais, ouvidos em Juízo, afirmaram que foram acionados via COPOM em razão de uma denúncia anônima no sentido de que na residência descrita na denúncia havia um indivíduo que estava vendendo drogas. No local foram atendidos pela genitora do réu, que franqueou a entrada. O réu estava tomando banho. Quando saiu, foi abordado e disse que não tinha nada de ilícito no local. Em cima de seu guarda-roupa foi encontrada uma sacola contendo 15 pinos com cocaína e R\$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em dinheiro. Indagado, o réu confirmou que a droga era dele e que exercia a traficância para pagar uma dívida com outro traficante, de nome Talisson. Por fim, disseram que não conheciam o réu.

Como se vê, o destino do entorpecente apreendido em poder do réu é manifesto, vez que tinha em depósito 10,9 gramas de cocaína acondicionada em 15 microtubos, prontos para imediata comercialização. Juntamente com a droga, na mesma sacola, foi localizada a quantia de R\$ 155,00 em dinheiro sem comprovação de origem lícita, ou seja, o produto do crime. Não bastasse, como já visto, o réu afirmou em Juízo que a droga realmente se destinava ao tráfico.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a finalidade de tráfico de entorpecentes é evidente.

Ressalto, apenas, que não há prova alguma nos autos de que o réu estaria sendo ameaçado/coagido por alguém a praticar o tráfico, muito menos de que essa suposta coação seria irresistível, de forma que inaplicável ao caso o disposto no artigo 22 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que a prova acusatória forma um todo coeso e concorde, perfazendo a necessária certeza para a prolação do decreto condenatório, ante estarem demonstradas, in casu, de forma indubitável, a autoria e materialidade delitiva, afastando-se toda e qualquer tese absolutória.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, em face da sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

O réu não ostenta antecedentes criminais. Analisando, ainda, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, deixo de reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e de o réu ser menor de 21 anos, pois a pena base já foi fixada no patamar mínimo legal, o que impede sua redução, nos termos da Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, embora não se discuta que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, não há prova de que o réu teria se valido de tal circunstância para facilitar ou permitir a prática do delito, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal não deve incidir. Nesse sentido: "1. Tráfico - Suficiência probatória - Condenações mantidas. 2. Penas - Pleito de elevação das básicas pelo número de porções das drogas e pela natureza mais nociva de parte delas, apesar de não expressivo o peso - Apreensão de cocaína e "crack", por si só, não autoriza exasperação - Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06 - Mesmas circunstâncias ademais suscitadas no pedido de cassação do redutor previsto no art. 33, § 4º, do estatuto antitóxicos - "Ne bis in idem". 3. Agravante do art. 61, II, "j", do CP - Configuração apenas quando o agente se prevalece da calamidade pública - Situação não verificada no caso, conquanto cometido o delito durante a pandemia do novo coronavírus. 4. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas - Ratificação - Benefício não obstado pelo montante ou pela qualidade do entorpecente, que só se presta a demonstrar a própria traficância, não dedicação a atividades delituosas nem participação em organização criminosa. 5. Regime inicial aberto e substituição - Cabimento - Ausência de hediondez do crime imputado - Art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação - Súmulas 718 do STF e 440 do STJ - Resolução 05/2012 do Senado Federal. (TJSP; Apelação Criminal 1508438-04.2021.8.26.0228; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/02/2022; Data de Registro: 14/02/2022)". "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EVIDENCIAM QUE O RÉU SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DOSIMETRIA - AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA - EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - NECESSIDADE. (TJSP; Apelação Criminal 1500940-34.2020.8.26.0536; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2022; Data de Registro: 03/02/2022)".

Na terceira fase de dosimetria penal, o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Isso porque, embora tecnicamente primário, o acusado, enquanto adolescente, cumpriu medidas socioeducativas de internação e de liberdade assistida pela prática de atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de entorpecentes (fls. 171/185). Logo após completar dezoito anos de idade, praticou o crime de tráfico objeto destes autos, sendo preso em flagrante. E, solto no dia 17 de julho de 2020 por ter sido beneficiado pela liberdade provisória (fls. 44/46), já no dia 25 de agosto de 2020 se envolveu na prática de crime de latrocínio tentado, do qual foi condenado em 1ª instância conforme consulta realizada, encontrando-se preso preventivamente por aquele por processo (nº 1501225-30.2020.8.26.0438 - fls. 91). Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que o acusado não possui emprego lícito comprovado nos autos, permitem concluir que ele não se trata de mero traficante ocasional, mas sim que se dedica

às atividades criminosas, fazendo do crime, em especial o tráfico, seu meio de vida e fonte de renda. Assim, o réu não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício ---"desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa---. Neste sentido: "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. SITUAÇÃO IDÔNEA A SER VALORADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE DROGA. USO NA PRIMEIRA FASE E NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack. IV - De mais a mais, o Tribunal de origem afirmou que o paciente "assume funções de chefia e direção em organização criminosa. Acrescente-se que, conforme documento de fl. 52, o réu apresenta inúmeras passagens pela Vara da Infância, fazendo do crime o seu meio de vida desde a adolescência" Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes" (AgRg no HC n. 588.716/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/08/2020). V - Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. VI - Ainda, insta consignar que é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.255.180/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/02/2013; HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017; AgRg no REsp n. 1.779.825/RO, Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/05/2019. VII - Regime inicial. A quantidade e a natureza do entorpecente - 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack - foram utilizadas como fundamentos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 641.285/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). "TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos guardas civis municipais em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada - Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (16 porções de 'maconha', com peso líquido

de 18,11 gramas), além de dinheiro e celular - Crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e envolvendo adolescentes - Condenação eskorreita. PENAS E REGIMES PRISIONAIS - Bases nos mínimos. Natureza e quantidade de droga que, embora relevante, não justificam a exasperação - Menoridade relativa e agravante do artigo 61, II, "j", do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública). Compensação - Exclusão do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Réu que ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, três delas por ato infracional equiparado ao tráfico. Causas de aumento do artigo 40, III e VI, da Lei de Drogas. Acréscimo de 1/5 - Regime inicial fechado - Apelo ministerial provido para afastar a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, majorar as penas e fixar o regime inicial fechado. (TJSP; Apelação Criminal nº 1501321-34.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Des. Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; Data de Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021). "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEFESA PLEITEIA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E A MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA QUE SEJA ELEVADA A PENA-BASE, AFASTADA A INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006, FIXADO O REGIME FECHADO E CASSADA A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS - COM INTEIRA RAZÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO - PENAS ALTERADAS - RÉU PRIMÁRIO, MAS COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DEDICAÇÃO AO NEFASTO COMÉRCIO DEMONSTRADA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA - IMPOSSIBILIDADE DE PERMUTA E DE RIGOR O REGIME FECHADO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE EMPREITADA CRIMINOSA - A MULTA NÃO PODE SER REDUZIDA, POIS JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL - EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal nº 1500927-84.2019.8.26.0628; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Des. Relator: Euvaldo Chaib; Data de Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020).

Portanto, ante a ausência de circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena aplicada.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra PEDRO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, e o condeno ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O regime para o cumprimento de pena é o inicial fechado, único recomendável diante da latente e concreta gravidade do crime (o réu se dedica ao tráfico de cocaína, substância altamente nociva, não se enquadrando o delito em questão na figura do chamado "tráfico privilegiado", como já visto), fomentador de tantas outras práticas ilícitas, restando evidentemente prejudicada a aplicação da Lei nº 9.714/98, mesmo porque os objetivos do legislador com a promulgação desta Lei demonstram que ela afeta apenas aos crimes menos graves, distanciam-se em muito da hedionda mercancia.

Demais disso, ainda que alguns requisitos do artigo 44, do Código Penal fossem favoráveis ao réu (o que não é o caso, vez que a pena aplicada é superior a quatro anos de reclusão), não estaria configurado o previsto pelo inciso III, in fine, do mencionado dispositivo legal, ou seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". O traficante é um grande responsável direto pela onda de violência que avassala o país. A insuficiência da substituição em tela para a repressão e prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes no caso concreto é patente, por conseguinte.

O réu poderá recorrer em liberdade, posto que respondeu a este processo nesta

condição.

Por fim, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, declaro perdidos em favor da União os valores descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 10, pois se tratam de produto do crime.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Araçatuba, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA